

1501117-27.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... operação para combate aos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de armas de fogo, em local já conhecido pela ocorrência da mercancia ilícita de entorpecentes, moradores informaram à equipe que, momentos antes, estava realizando a venda de drogas em um ponto de tráfico um indivíduo trajando blusa colorida, de prenome Alexandre, que residia em uma casa com muro branco ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501117-27.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501117-27.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, em ocasião de calamidade pública, tinha em depósito, para fins de tráfico, 49 porções de maconha, 31 porções de cocaína, 105 pedras de crack e quatro unidades de skunk, substâncias que causam dependência física e psíquica, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Foram também apreendidos, juntamente com as drogas, a quantia de R\$17,00 e um cartão bancário em nome de terceira pessoa.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar. A denúncia foi recebida e o réu foi citado.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e, ao final, foi o réu interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pediu a procedência da ação para condenação do réu nos termos da denúncia, diante da prova produzida. Formulou, ainda, pedidos

quanto à fixação da pena e do regime prisional.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, alegando falta de provas. Subsidiariamente, formulou pedidos relativos à dosimetria da pena e à fixação do regime prisional.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo auto de constatação, pelo laudo de exame químico-toxicológico, bem como pelo conjunto probatório constante dos autos.

Também não restam dúvidas quanto à autoria do delito.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do crime descrito na denúncia.

Contou que o local dos fatos, referido pelos policiais, não era a sua casa, mas, sim, a residência de sua mãe, onde havia passado após o trabalho para buscar sua esposa. Disse que, ao lado da casa, ocorre o tráfico de drogas e também há um beco. Alegou que estava sentado à porta da casa de sua mãe e que, quando os policiais chegaram ao local, indivíduos correram e uma bolsa foi jogada no beco. Contou que os policiais o questionaram sobre quem havia corrido e quem estaria na casa, tendo respondido que não sabia quem eram os indivíduos e que, na casa de sua mãe, somente estava sua família. Disse que os policiais informaram que realizaria uma busca no local, porém sua mãe os questionou e pediu que pudesse acompanhar os trabalhos, mas, tendo os policiais dito que se ela causasse problemas todos seriam encaminhados à delegacia, pediu que sua mãe autorizasse a entrada deles. Contou que, realizada a busca, os policiais nada encontraram na casa, mas, em seguida, foram ao beco, de onde trouxeram uma bolsa. Negou que a droga encontrada fosse de sua propriedade. Disse que trabalha com seu irmão durante a semana, realizando mudanças e outros serviços, e aos domingos vende comida. Alegou que não trajava casaco colorido e não possuía nenhuma bolsa em seu poder. Disse que já havia visto os policiais que o abordaram em ronda pelo bairro. Contou que possivelmente foi incriminado porque era a única pessoa próxima à droga, pois todas as demais pessoas correram e a bolsa foi jogada no beco. Disse que foi fotografado na delegacia com a roupa que estava vestindo naquela data.

Contudo, a negativa do réu e a versão por ele fornecida encontram-se isoladas no contexto probatório.

A testemunha policial militar Pablo dos Santos Matos, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que, durante operação para combate aos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de armas de fogo, em local já conhecido pela ocorrência da mercancia ilícita de entorpecentes, moradores informaram à equipe que, momentos antes, estava realizando a venda de drogas em um ponto de tráfico um indivíduo trajando blusa colorida, de prenome Alexandre, que residia em uma casa com muro branco e azul, onde havia uma placa com anúncio de venda de "chup-chup", sendo que ele estaria portando uma bolsa preta. Narrou que realizou busca pela casa indicada e avistou o acusado saindo do imóvel, notando que ele assustou-se com a presença da equipe policial. Declarou que, diante das informações que foram fornecidas à equipe policial, foi realizada a abordagem do acusado. Disse que, questionado sobre o tráfico de drogas, o acusado inicialmente negou a prática do crime. Relatou que a equipe policial estava com um cão farejador e este alterou o comportamento em frente à casa do acusado. Narrou que o réu, informado que o cão realizaria a busca nas imediações, acabou por admitir a prática do tráfico de drogas, informando que a bolsa com os entorpecentes estava dentro de sua casa. Declarou que o réu ingressou no imóvel com seu parceiro de farda, Soldado Santos, indicando a este onde estava a bolsa, que foi apreendida. Relatou que o acusado, também informalmente, declarou que, por estar desempregado há três meses, estava realizando o tráfico de drogas, pelo qual recebia R\$25,00 a cada R\$100,00 de entorpecentes vendidos. Consignou que toda a droga encontrada estava na bolsa preta e tratava-se de maconha, crack, skunk e cocaína, sendo também apreendida a quantia de R\$17,00 e um cartão. Esclareceu que, quando populares indicaram o indivíduo que traficava, fizeram a ressalva de que no local dos fatos havia indivíduos armados, mas não apontaram o réu como sendo um dos que portavam arma. Relatou que o acusado foi questionado sobre arma de fogo e negou possuí-la, sendo que nenhum armamento foi apreendido em sua residência.

Afirmou que a abordagem do acusado e a busca no local ocorreram após ser constatado que as características do réu coincidiam com aquelas descritas por populares e por ter o cão farejador alterado o comportamento, por sentir o rastro de drogas, diante do imóvel do acusado, que também acabou por admitir, informalmente, a prática do delito.

No mesmo sentido, a testemunha policial militar Matheus Leite Santos, ouvida em Juízo, narrou que, em operação para coibir o tráfico de drogas e o porte ilegal de armas, ingressou em um beco, onde moradores das imediações noticiaram que, próximo a uma residência de muro branco e azul, com uma placa de venda de "chup-chup", um indivíduo de prenome Alexandre, trajando roupa colorida, estaria portando uma bolsa preta e praticando o tráfico de drogas. Relatou que, ao averiguar a notícia, visualizou o réu saindo da residência indicada. Consignou que estava conduzindo o cão farejador e, questionado o acusado sobre o crime de tráfico, ele inicialmente negou a prática ilícita, mas ao ser informado de que o cão, que havia alterado o comportamento, detectaria a presença de entorpecentes, acabou por admitir a realização do tráfico, indicando que as drogas estavam dentro da casa. Disse que o acusado entrou consigo no imóvel e mostrou o local onde estava a bolsa preta que continha os entorpecentes, sendo esta apreendida. Declarou que as drogas encontradas na bolsa eram cocaína, maconha, crack e skunk, e com elas também havia dinheiro. Esclareceu que a operação que realizava na data dos fatos ocorre em toda a Baixada Santista e que já havia feito tais diligências naquele mesmo bairro, mas não conhecia o acusado anteriormente aos fatos. Consignou que, diante da notícia recebida por moradores, que davam as características do réu, seu nome e sua residência, e, sendo localizada a casa, diante da alteração do comportamento do cão, que somente ocorre ao sentir odor de drogas, havia elementos para a realização do flagrante.

Não há dúvidas, portanto, sobre a conduta criminosa do acusado, no que se refere ao tráfico de drogas, diante das provas produzidas.

Ressalta-se a palavra dos policiais, que de maneira segura, uniforme e convergente, descreveram com detalhes como ocorreu a diligência ao local dos fatos, a apreensão das drogas que o réu tinha em depósito em seu imóvel, bem como de que forma ocorreu a identificação do acusado.

Não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade dos testemunhos policiais.

Como já se decidiu "é bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando ele fosse convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor, aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade" (Apelação criminal nº 112.195-3/1, Santos, Rel. Des. Canguçu de Almeida, em 07/10/1991, 2ª Câmara Criminal). Aliás, mostra-se "imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que o depoimento de policiais responsáveis pela segurança pública, não podem ser desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem função de salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento" (TJSP - AP - Rel. Walter Guilherme - j. 10.03.98 - JTJ 214/284). Ademais, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de manifestar-se favoravelmente à validade desses depoimentos. A propósito, registro: "Tóxicos - Tráfico - Prova testemunhal: Depoimento de policiais. A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho

realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente" (STF - 2. T. - HC nº 74.522-9/AC - Rel. Mm. Maurício Correa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais -Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1a Turma - HC n. 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO INCORRETO. MENORIDADE RELATIVA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO À MÍNGUA DE PEDIDO NO RECURSO MINISTERIAL. REGIME FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada em poder do réu.

2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP - Rel. Min. Moura Ribeiro - j. 27.05.14; RHC 45.173/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 26.05.14 e HC 109.105/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.02.10).

3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou

outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa.

Precedentes do STF (AP 470/MG – Pleno – Voto Min. Cezar Peluso – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG – Pleno – Voto Min. Luiz Fux – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 838/842).

4. Dosimetria da pena estabelecida de modo incorreto. Menoridade relativa. Correção de ofício.

5. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primordialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF (HC 121.057/SP – Rel. Min. Luiz Fux – j. 25.02.14 – DJU 18.03.14; HC 118.380/SP – Rel. Min. Teori Zavascki – j. 04.02.14 – DJU 14.02.14; HC 116.541/ES – Rel. Min. Gilmar Mendes – j. 21.05.2013 – DJE 06.06.13; HC 109.236/SP – Rel. Min. Cármen Lúcia – j. 13.12.11 – DJU 14.23.12). Manutenção à míngua de pedido no recurso Ministerial.

6. O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

7. Provimento do recurso do Ministério Público e correção, "ex officio", da dosimetria da pena." (Ap. nº 3003382-41.2013.8.26.0471; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Porto Feliz; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 01/06/2016; Data de registro: 07/06/2016) (grifo nosso)

"Tráfico de entorpecentes – Agente que mantém em depósito e guarda substância estupefaciente – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Caracterização

Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e de "guardar".

Tráfico de entorpecentes – Agente que vende substância estupefaciente a policial pensando tratar-se de consumidor – Apreensão que quantidade expressiva de entorpecente por ele guardado – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com o conjunto probatório e com a quantidade de entorpecente apreendida

Realiza o tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 o agente que vende substância estupefaciente a policial, pensando tratar-se de consumidor. Ainda que assim não fosse, o próprio estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente não é necessário para caracterizar o tráfico, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e "guardar". A ulterior alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso próprio não se coaduna com a dinâmica de sua apreensão, devendo ser afastada.

No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena – Tráfico de Entorpecentes – Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP em razão da quantidade e a

variedade do entorpecente apreendido - Admissibilidade

Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na variedade e qualidade do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

Cálculo da Pena - Tráfico de entorpecentes - Desnecessidade de comprovação de nexos causal entre a conduta do acusado e a circunstância da apreensão ter ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino - Causa de aumento de pena (art. 40, III, da Lei nº 11.343/06) de natureza objetiva - Reconhecimento

Imperioso o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 sempre que for constatado que o tráfico de drogas estava sendo praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. Em tal situação, torna-se dispensável a comprovação de que o acusado comercializava entorpecentes erigindo diretamente os alunos da escola como público alvo, uma vez cuidar-se de causa de aumento de natureza objetiva." (Ap. nº 0039706-12.2014.8.26.0224; Relator(a):

Grassi Neto; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal;

Data do julgamento: 19/05/2016; Data de registro: 19/05/2016) (grifo nosso)

O esforço da Defesa em desqualificar os depoimentos das testemunhas policiais não é suficiente para retirar a força probante deles.

As acusações contra os policiais militares que participaram da prisão em flagrante do réu não vieram acompanhadas de qualquer elemento probatório.

Argumentos genéricos que visam a desprestigiar a Polícia como um todo em nada influenciam na prova colhida no presente caso.

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais militares colhidos durante a instrução criminal mostram-se coerentes e harmônicos quanto às circunstâncias em que se deu a ação policial, a identificação do acusado e a localização dos entorpecentes, e encontram-se em verdadeira consonância com suas declarações prestadas perante a Autoridade Policial.

Note-se que as testemunhas policiais militares bem esclareceram, pormenorizadamente, que, em operação para combate aos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, receberam notícia de moradores acerca do indivíduo que estaria realizando a venda de entorpecentes, com informação sobre seu nome, sua vestimenta e sobre o local onde ele residia, e, em razão das indicações precisas, puderam localizar a casa e avistar o acusado dela saindo.

Afirmaram, ainda, que a equipe policial era acompanhada de um cão farejador e este, diante da residência do réu, alterou seu comportamento, o que somente ocorre quando o animal detecta a presença de drogas.

Asseveraram que, apesar do acusado inicialmente ter negado a prática do crime, acabou por admitir, informalmente, que dentro de sua casa estava a bolsa preta contendo drogas, que foi localizada e apreendida, verificando-se nela haver cocaína, maconha, crack e skunk.

De outro lado, nenhuma testemunha arrolada exclusivamente pela Defesa foi trazida em Juízo para ser ouvida, a fim de esclarecer os fatos ou, ao menos, contrariar concretamente a versão apresentada pelas testemunhas policiais.

Assim, a negativa do réu e a versão por ele apresentada de que estaria sentado à porta da casa de sua mãe e que, após indivíduos fugirem e jogarem uma bolsa em um beco, os policiais - que sequer o conheciam anteriormente aos fatos - o abordaram, realizaram busca naquela residência sem nada encontrar e, após, apreenderam a bolsa que estava no beco, atribuindo-lhe falsamente a propriedade dela, não se mostraram críveis e restaram absolutamente isoladas do contexto probatório, devendo-se considerar os demais elementos de convicção existentes e produzidos durante o processo.

Na hipótese, seria mesmo um contrassenso pretender que a versão fornecida pelo acusado sobreponha-se aos depoimentos dos policiais militares encarregados de sua prisão, depoimentos estes que estão em harmonia com as demais circunstâncias que envolvem o delito.

Em outras palavras, impossível seria desmerecer os depoimentos dos policiais, pois são absolutamente aptos e suficientes para embasarem a inequívoca conclusão de que o réu é de fato traficante.

No presente caso os elementos de convicção são contundentes, seja em virtude da

variedade e da quantidade das drogas apreendidas, seja pela ação policial, tudo aliado à negativa isolada do réu.

Gize-se, ainda, que a falta de testemunhas civis que tenham presenciado a ação policial e a abordagem não retira a validade e força probante das declarações prestadas pelas testemunhas policiais.

É amplamente sabido que testemunhas civis sobre crimes ligados ao tráfico de drogas são muito difíceis de serem levadas perante a Autoridade Policial, pois o medo que impregna a população acerca do mencionado crime é reflexo da estruturação advinda dele, alimentada pelos vultosos lucros conseguidos e pelo chamado “código de ética”, pregado, na maioria das vezes, nos locais mais humildes, o qual, se desobedecido, os colaboradores pagam com a própria vida.

Outrossim, nenhuma ilicitude há na informação anônima recebida pelos policiais militares. Sobre esse tema decidiu o Des. Rachid Vaz de Almeida (Apelação nº 0002730-56.2014.8.26.0272, 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – 25/08/2016):

“Quanto ao anonimato da denúncia, a leitura que deve ser feita da Constituição Federal (artigo 5º, inciso IV) é de que a vedação se dirige a manifestações de pensamento proferidas na imprensa escrita ou falada, visando coibir excessos nas veiculações de notícias.

Tratando-se de delação anônima e investigação estatal, já se pronunciou o e. Supremo Tribunal Federal:

O veto constitucional ao anonimato, como se sabe, busca impedir a consumação de abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento, pois, ao exigir-se a identificação de quem se vale dessa extraordinária prerrogativa político-jurídica, essencial à própria configuração do Estado democrático de direito, visa-se, em última análise, a possibilitar que eventuais excessos, derivados da prática do direito à livre expressão, sejam tornados passíveis de responsabilização, “a posteriori”, tanto na esfera civil, quanto no âmbito penal (MS. 24.369-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 10.10.2002, pub. DJU de 16.10.2002).

Com efeito, não há vedação de ordem constitucional ou legal à notícia anônima de crime.

Por outro lado, há de se considerar o incentivo do Poder Público no sentido de que a população informe às autoridades acerca de fatos criminosos e que tenham conhecimento, visando, assim, dar mais efetividade à prevenção e à repressão o crime.

Nessas situações, como vem sendo amplamente divulgado, a pessoa sequer é compelida a se identificar, o que inequivocamente estimula a participação da comunidade no combate à criminalidade.

Portanto, seria um contrassenso estimular a sociedade a denunciar uma atividade delituosa para, depois, infirmar esse elemento de convicção e considerar contaminadas todas as provas subsequentes, ainda que produzidas lícitamente a partir daquela.

Assim, não se revela ilícita, no caso em exame, as informações anônimas recebidas pela polícia via telefone 190, Disque Denúncia, e que deram ensejo às investigações pelo setor de inteligência da Polícia Militar.”

E apenas para consignar, não há nada nos autos que pudesse justificar a conclusão de que o réu estaria sendo acusado injustamente da prática do delito de tráfico de drogas.

Dessa forma, pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado, evidencia-se, pois, a realização do tráfico por ele.

Em arremate, a intenção mercantilista do réu deriva da variedade e da grande quantidade de drogas e demais circunstâncias em que estas e o dinheiro foram apreendidos.

De mais a mais, “para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc.” (TJRJ – AC 1.327/92 – Rel. Adolphino A. Ribeiro – RDTJRJ 20/310). Finalmente, não há se cogitar em nulidade da prova pela alegada “invasão a domicílio” cometida pelos policiais.

Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, visto que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se protraí no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância.

É a hipótese do crime de tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito", de natureza permanente e, portanto, reitera-se, tem sua consumação protraída no tempo. A entrada dos policiais era justificada pela situação de flagrância constatada. Note-se que, no presente caso, havia a fundada suspeita da prática do tráfico de drogas no local dos fatos. Confira-se:

Como evidenciado pela prova colhida nos autos, a diligência na residência do acusado, onde foi encontrada a bolsa contendo grande quantidade de drogas variadas não ocorreu de forma aleatória.

Havia notícia acerca do tráfico de drogas, recebida pelos policiais momentos antes, por moradores locais, durante operação por eles realizada naquela data. Diante das características informadas sobre o indivíduo de prenome Alexandre que estaria realizando o tráfico de entorpecentes, portando uma bolsa preta, trajando vestimenta colorida, e que residiria em uma casa de muro branco e azul com uma placa anunciando venda de "chup-chup", os policiais localizaram o imóvel e avistaram o réu, que possuía as mesmas características noticiadas.

Asseveraram os policiais que a equipe estava acompanhada de um cão farejador e, diante da alteração do comportamento do animal, bem como pela constatação de que todas as demais características do acusado e de sua residência eram compatíveis com as indicadas por populares, realizaram a abordagem do acusado, que acabou por admitir a prática do crime e indicar o local, dentro de sua residência, onde estava a bolsa contendo os entorpecentes.

Não se pode alegar, portanto, qualquer tipo de conduta abusiva por parte dos policiais ao entrarem no local, nem que tenham agido de forma aleatória, repita-se. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, quando do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.

Transcreve-se, a seguir, a mencionada tese:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas "a posteriori", que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

No mesmo sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas e Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido com Numeração Suprimida – Preliminar - Violação de Domicílio - NÃO VERIFICADO - Presente in casu a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão pelos policiais sem mandado judicial. Ademais, em se tratando de delito permanente, cujo estado de flagrância se perdura no tempo, a diligência policial, em residência, pode ser feita a qualquer hora do dia ou da noite, prescindindo até mesmo da existência de uma determinação judicial para tanto, em conformidade como disposto no art. 5º, XI, da CF/88. Precedente do STF. No mérito, insurge-se contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea. Aduz, ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP – IMPOSSIBILIDADE – A decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, lastreada na expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, arma de fogo e circunstâncias do fato, elementos a denotar maior reprovabilidade da conduta e periculosidade social do paciente - Periculum Libertatis - Garantia da ordem

pública. Precedentes do STJ. Ordem denegada." (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2140716-14.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/07/2021; Data de Registro: 22/07/2021)

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT E LEI N. 10.826/2003, ART. 12, CAPUT) - PRELIMINAR DE NULIDADE - INVASÃO DE DOMÍLIO - Não há nulidade por violação de domicílio quando o policial adentra à casa do acusado, diante da fundada suspeita de tráfico de drogas, por configurada a situação de flagrante (art. 5º, XI, da CF), notadamente em se tratando de crime de natureza permanente. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada, que indicaram que dentro do imóvel ocorria situação de flagrante delito. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES CONDIZENTES COM A REALIDADE DOS AUTOS - ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A COMPROVAR O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO - Não há falar-se em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e autoria dos delitos. REDUÇÃO DA PENA-BASE - Possibilidade. Dolo normal ao tipo. Penas redimensionadas. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos legais. Não pode ser aplicada em razão da grande quantidade de droga apreendida, elemento que demonstra que os apelantes se dedicavam à atividade criminosa. ALTERAÇÃO DO REGIME - Impossibilidade. Deve ser mantido o regime prisional fechado para o crime de reclusão e semiaberto para o apenado com detenção. Tamaña a quantidade de drogas e munições apreendida, qualquer outro regime não se mostraria recomendável. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - Inviabilidade. Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o apelante foi condenado à pena corporal superior a 04 (quatro) anos de reclusão. PREQUESTIONAMENTO - Afigura-se desnecessária a abordagem pelo órgão julgador de toda a matéria debatida pela parte, mesmo diante do prequestionamento para efeito de interposição de Recursos. DETRAÇÃO - O pedido para que seja efetuada a detração penal deverá ser analisado pelo Juízo de Execuções Penais. Recurso da defesa parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 1525924-36.2020.8.26.0228; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 07/07/2021)

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Insurgência contra suposta violação ilegal de domicílio. Inocorrência. Elementos de prova a indicarem que o ingresso foi escorado em fundadas suspeitas de que lá se praticava crime, com confirmação decorrente da apreensão de considerável quantidade de drogas para o tráfico, segundo confissão. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Condenação mantida. Penas dosadas com rigor exacerbado, com fundamentação inidônea. Apelo provido em parte, apenas para reduzir as reprimendas de PEDRO a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, e de ALEXANDRE a 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença. " (TJSP; Apelação Criminal 0003609-60.2020.8.26.0302; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaú - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico ilícito de drogas Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 1. PRELIMINAR Nulidade decorrente de prisão efetuada por guardas civis Descabimento - Nota-se, em primeiro lugar, que se trata de crime de tráfico ilícito de drogas, delito de natureza permanente Ademais, qualquer pessoa pode realizar a prisão em flagrante, bem como as autoridades devem assim proceder Não se vislumbra qualquer exceção à atuação de guardas municipais, integrantes dos quadros de força pública no âmbito municipal -Prova ilícita em razão de invasão de domicílio Não cabimento Em se tratando de crime de tráfico ilícito de drogas, delito de natureza permanente, a ausência de mandado não macula a busca e apreensão (...)(TJ-SP - APR: 15014712820208260599 SP 1501471-28.2020.8.26.0599, Relator:Silmar Fernandes, Data

de Julgamento: 21/06/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/06/2021)

"Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Arguição de ilicitude probatória nos procedimentos que cercaram a prisão em flagrante consiste na violação do domicílio sem prévia investigação ou ordem judicial. Liminar deferida. 1. Ilicitude probatória não configurada. Intervenção policial que, a princípio, foi motivada pelo quadro de justa causa. Ação motivada por denúncia anônima que indicou o endereço e a pessoa responsável pelo armazenamento das drogas. Uma vez no local, os policiais avistaram o paciente que ao notar a aproximação da viatura correu para o interior do imóvel que havia sido referido na denúncia. Ilegalidade que não se mostra evidente. Necessidade de aprofundamento da questão ao longo da instrução. 2. Fumus comissi delicti dado pelos elementos informativos colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante. Visibilidade e imediatidade da prática delituosa. Quadro de justa causa configurado. 3. Não demonstração do periculum libertatis. Quantidade de drogas pequena. Paciente primário. A ausência de comprovante de ocupação lícita não é, no caso dos autos, elemento suficiente a justificar a imposição da medida extrema. Ausência de elementos indicativos da gravidade concreta. Precedentes. 4. Medida extrema que se apresenta desproporcional. Suficiência das medidas cautelares alternativas. 5. Ordem concedida. (TJ-SP - HC: 22255992520208260000 SP 2225599-25.2020.8.26.0000, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 16/10/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/10/2020)

O próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça adota esse entendimento, conforme recentes decisões:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. ALEGADA NULIDADE DO FEITO. BUSCA PESSOAL REALIZADA. RÉU NA POSSE DE PORÇÃO DE DROGA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. ANÁLISE NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça - STJ é sedimentada no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" ou "ter em depósito" é do tipo permanente, cuja consumação protraí-se no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, desde que haja fundada razão da existência do crime. No caso dos autos, durante patrulhamento, policiais observaram que o agravante estava em frente ao estabelecimento comercial e demonstrou nervosismo. Então, o abordaram e apreenderam uma porção de maconha, logo em seguida entraram em sua residência nos fundos do estabelecimento, com sua anuência. Assim, conforme se observa, somente após os policiais realizarem rondas nas proximidades do local e, diante da atitude suspeita do réu, adentraram no imóvel, juntamente com o mesmo, onde encontraram mais drogas divididas em cinco porções (cerca de 1,5kg de maconha), confirmando a prática do delito e realizando a prisão em flagrante do paciente. 2. A questão referente à situação de emergência decorrente da pandemia da COVID-19, não foi debatida no acórdão atacado e, deste modo, este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RHC 130.515/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. 1. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 2. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais

hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, como bem destacado no acórdão recorrido, "a Polícia Militar diligenciou no sentido de apurar fundada suspeita da prática de crime de tráfico de entorpecentes em sua residência". 3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. No caso, foram apreendidos com o paciente 508,10g de crack, além de 4 pinos de cocaína. 5. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. 6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido." (RHC 140.916/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. DINÂMICA DELITIVA QUE INDICA A PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AGENTE QUE NÃO PORTAVA DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS NO HC. 598.051/SP. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. II - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo que se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. III - No caso, ao desobedecer o sinal de parada dado pela Guarda Municipal, o agravante se evadiu e foi perseguido por 15 km até ser interceptado. Admitindo ser foragido da Justiça Pública, o agente, que não portava documentos de identificação, foi conduzido até a sua residência, local onde foram encontrados mais de 9,278 kg de cocaína e tambor contendo lidocaína, situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando a dinâmica do flagrante (desobediência à ordem de parada, evasão, ausência de porte de documento de identificação e reiteração delitiva), bem como o flagrante do tráfico ilícito de entorpecente materializada na conduta do paciente de guardar a droga em sua residência, caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial. IV - O feito em análise se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão

acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021), é dizer: a desobediência à ordem de parada da autoridade e evasão, por vias públicas, por 15 km até a sua interceptação; a condição de foragido da Justiça Pública sem a devida identificação na abordagem; o cumprimento do dever legal de proteção da autoridade em diligenciar a correta e indispensável identificação do paciente são circunstâncias fáticas sinalizadoras do ingresso regular no domicílio, de onde iniciou a fuga, tanto que encontrada alta quantidade de droga de alto potencial ofensivo. V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada a pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 656.042/SP, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021)

Dessa forma, provadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, considerando-se a natureza, a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da prisão, a condenação do réu é medida que se impõe.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena do delito de tráfico de drogas.

Diante da natureza e variedade das drogas apreendidas, circunstâncias que demonstram a maior periculosidade do réu, pois não se trata de pequeno traficante, mais sim de um grande disseminador dos entorpecentes, fixo sua pena-base acima do mínimo legal em 1/6, ficando ela estabelecida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Na segunda fase de fixação da pena, verifico que o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública. Em que pese a vigência somente até 31 de dezembro de 2020 do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em âmbito federal, verifica-se que o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, decorrente da pandemia do COVID-19, foi reconhecido por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que ainda se encontra em vigência diante de sucessivas prorrogações. Portanto, em âmbito estadual, mantiveram-se vigentes as normas referentes ao reconhecimento do estado de calamidade pública. A agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. A pena deve ser acrescida de 1/6, ficando fixada em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor já estipulado.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causa de aumento a ser reconhecida, e não se pode reconhecer a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, diante da grande quantidade da droga apreendida.

Não caracteriza ofensa ao princípio do ne bis in idem a utilização da natureza da droga como circunstância judicial negativa para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria e o reconhecimento da grande quantidade de drogas, na terceira fase, para fins de modular ou afastar a redutora prevista na Lei de Drogas.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. MODULAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA. BIS IN IDEM NÃO VERIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA ALTERNATIVA. PENA